

1533522-56.2021.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

4ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1533522-56.2021.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1533522-56.2021.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2273897/2021 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 20697305 - 77º D.P. SANTA CECILIA, 2273897 - 77º D.P. SANTA CECILIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

VISTOS

DIOGO FELIPE GABRIEL LIMA, SUELLY APARECIDA DA SILVA, ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA e DANILO GOMES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 8h30min, durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID 19, na Praça Princesa Isabel, 1, Santa Cecilia, nesta Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para fins de tráfico, 5 porções de cocaína (2,8 gramas), 2 porções de cocaína na forma de "crack" (21,2 gramas), 11 porções de cocaína na forma de "crack" (63,0 gramas) e

2 porções de cocaína na forma de "crack" (21,7 gramas), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a denúncia, na data dos fatos os acusados se dedicavam à traficância no local, guardando e trazendo consigo, na via pública, os entorpecentes, além de dinheiro sem origem comprovada.

Na região da "cracolândia", junto ao "Projeto Redenção", guardas civis metropolitanos foram informados por seu setor de monitoramento que um casal de traficantes, DANILO e SUELY estavam deixando o "fluxo", indo em direção à Praça Princesa Isabel, na companhia de DIOGO e ANDRÉ.

Após breves diligências no local, os guardas civis avistaram os acusados atravessando a Avenida Rio Branco. Ao serem abordados, ANDRÉ tentou se evadir, e foi detido. Em seu poder havia uma bolsa feminina branca, contendo uma pedra de "crack" com 63 gramas, uma balança, um prato e dois pedaços de vidro, além de R\$2.275,00 em dinheiro trocado.

Com DANILO foram localizadas duas pedras de "crack" com 21,7 gramas e R\$162,00 em notas trocadas; com SUELLY estavam onze pedras de "crack" com 21,7 gramas, cinco porções de cocaína com 2,8 gramas e R\$144,00 e com DIOGO R\$512,00 em moedas e uma corrente dourada, além de documentos de terceiro.

DIOGO disse aos guardas que iria ganhar uma "pedra de crack" para levar as moedas para um táxi, a pedido de ANDRÉ e DANILO. Todos os acusados permaneceram silentes para a autoridade policial.

Os réus foram presos em flagrante, sendo decretada as suas prisões preventivas. Pela celeridade processual, o rito foi convertido em ordinário e a denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2021 (fls. 284/286).

Os réus foram citados, foram apresentadas respostas à acusação e houve ratificação do recebimento da denúncia.

Durante a instrução processual foram ouvidas testemunhas e, após os réus foram interrogados.

Deu-se cumprimento ao disposto no art. 402 do Código de Processo Penal.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público, após a análise das provas produzidas, postulou a condenação dos réus nos termos da denúncia.

O Dr. Defensor Público, por SUELLY. DIOGO E DANILO, por seu turno, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição.

Subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal e regime menos gravoso, e, com relação a SUELLY aplicação do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

A defesa de ANDRÉ, argumentou com fragilidade do conjunto probatório, pelo que postulou sua absolvição. Subsidiariamente, a desclassificação do art. 35 da Lei nº 11343/06, aumento pela reincidência em apenas 1/6, afastamento da agravante da calamidade pública.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As substâncias apreendidas (fls. 14/15) foram submetidas a exame químico-toxicológico, tendo resultado positivo para cocaína, listadas entre as que determinam dependência física e psíquica (fls.321/323), corroborando o auto de constatação de fls. 17/20. Provada, portanto, a materialidade delitiva do tráfico de entorpecentes.

A autoria do crime pelos réus, outrossim, restou demonstrada pela prova oral coligida nos autos.

Em Juízo, DANILO negou a prática do delito. Estava no local usando drogas, usou drogas a noite toda e tinha que trabalhar. Saiu do hotel para trabalhar, "mexe com eventos", estava com duas "pedras de crack" e R\$212,00. Foi abordado sozinho. Uns rapazes correram, um guarda lhe abordou. Disse a ele que estava usando drogas, mas não vendendo. Tem uma condenação por tráfico de drogas, estava há 30 dias na rua. ANDRÉ negou a prática do delito. Estava no local indo no sentido do "fluxo", foi comprar "crack e cocaína". Não chegou a entrar no "fluxo" e foi abordado. Correu antes de ser abordado, estava evadido de "saidinha". Os policiais conseguiram lhe abordar e disse que era foragido. Estava sozinho, não conhece os corréus. Os

policiais acharam com um dos rapazes, ficaram irritados com ele porque ele correu. Não estava com droga. Estava com apenas R\$30,00, os guardas plantaram mais de R\$2.000,00 para incriminá-lo. Só foi processado por roubo. Não estava com balança, pires, vidros.

SUELLY negou a prática do delito. Estava no local "fazendo programa" e o cliente pediu para comprar drogas para eles. Foi abordada sozinha, só soube que havia mais gente na Delegacia de Polícia. Só tinha cocaína, não "crack". Não conhecia os GCMs antes, não sabe por que estão dizendo que tinha mais droga. Tinha R\$144,00 que sobrou do programa. Está respondendo outro tráfico de drogas. É prostituta. Usa cocaína todos os dias, busca na "cracolândia" suas drogas.

DIOGO negou a prática do delito. Trabalha com reciclagem e "Ceará" do ferro velho pediu para pegar no "bar do seu João" para pegar troco para ele. Eles são irmãos. O bar é na Rua Helvetia. Pegou o troco em moedas, cerca de R\$500,00. Foi abordado pelos GCMs, foi abordado sozinho, mas a moça e os dois rapazes foram abordados mais para trás. "Catava" reciclagem na região. Não conhecia os guardas antes. Não sabe o número do bar na Rua Helvetia. Já foi processado antes, mas não por tráfico, por roubo. Usa crack, maconha e cocaína.

As versões dos acusados, contudo, restaram isolada no conjunto probatório produzido, e a eles incumbia a prova de suas alegações, a teor do art. 156 do CPP, o que não foi feito.

Ademais, absurda a alegação dos acusados de que os guardas civis teriam "plantado" mais de R\$2.000,00 para incriminar acusados que não conheciam, como dito pelos próprios réus.

A prova produzida pela acusação é suficiente para a condenação.

O Guarda Civil Metropolitano Marcelo Ribeiro Duas, reconhecendo os réus em audiência, afirmou que estava na região da "Cracolândia" e o monitoramento por vídeo da GCM com imagens boas e nítidas lhes passou, acha que é "Citycam", sistema que acha que é estadual ou federal, na área da "Cracolândia". Não viu as imagens. Passaram as características e o local onde estavam as pessoas traficando, que coincidiam com as dos réus. Dois foram contidos pelo motorista e deteve DANILO. Quando os encontraram, localizaram com eles drogas e dinheiro. Não se recorda o que eles falaram quando detidos e nem quem estava com o quê.

Suas palavras foram ratificadas pelas de seu colega, o Guarda Civil Metropolitano Douglas Henrique Carneiro, que também reconheceu os acusados e acrescentou que não conhecia os réus antes e trabalha no local há 14 anos. A rede passou as características das pessoas que estaria praticando tráfico e local. Um correu no sentido do "fluxo", ANDRÉ, e conseguiu abordá-lo. Ele disse só "perdi". Seus parceiros prenderam os demais. Encontraram dinheiro e drogas com eles, mas não sabe o quê estava com quem. O "casal" disse que estava só transportando drogas. ANDRÉ disse que era do crime organizado, deu nome errado. O monitoramento falou que era um casal mais dois homens. Os demais foram presos pelo motorista da viatura. Não os viu vender drogas.

As palavras dos guardas civis possuem plena validade, pois, como agentes públicos que até prova em contrário - não produzida nestes autos - estão a serviço da lei e da ordem. Em favor dos agentes há a presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções (JTJ 154/302, 159/310), presunção essa aqui não elidida.

Ainda:

"DEPOIMENTO DE POLICIAL. Valor probante. A tese da insuficiência testemunhal, quando emane de agentes da Polícia, consiste em velharia em boa hora mandada ao bolor dos armários de reminiscências especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem alguma para que se repudie a palavra de, precisamente, pessoas a quem o Estado confere a missão importantíssima de coibindo o crime, operar, e nada menos, a própria prisão. Não se legitima atribuir ao Estado essa insensatez" (RJTJESP 136/477).

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência." (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996).

Assim, o conjunto probatório carreado aos autos é seguro para a condenação do acusado nos termos da denúncia.

A quantidade de droga encontrada é expressiva e, por conseguinte, evidenciadora de sua destinação ao consumo de terceiros, principalmente considerando o local da prisão - a chamada "Cracolândia", ainda considerando a quantidade elevada de dinheiro apreendida - valendo lembrar que traficantes raramente são presos com quantidade alentada de narcótico, não sendo comum, outrossim, o estoque, por mero usuário, não dependente, de grande quantidade de substância entorpecente para o próprio consumo.

De fato, foram apreendidos, um total de 5 porções de cocaína (2,8 gramas), 2 porções de cocaína na forma de "crack" (21,2 gramas), 11 porções de cocaína na forma de "crack" (63,0 gramas) e 2 porções de cocaína na forma de "crack" (21,7 gramas), sendo capazes de produzir mais de 529 "pedras de crack" e cerca de 28 fileiras de cocaína, e assim, suficientes para o comprometimento de um número grande de usuários.

Logo, tudo nestes autos revela que os réus guardavam e traziam consigo as substâncias entorpecentes apreendidas para fins de mercancia e entrega a consumo de terceiros, haja vista que a prova dos autos, inclusive a indiciária, se erige suficiente confirmação do tráfico.

Não se pode olvidar, a propósito, que, para a caracterização do delito previsto no art. 33 da nova Lei de Drogas, não se exige efetivo ato de tráfico, bastando que o agente tenha consigo a substância entorpecente para tal finalidade, não havendo que se falar em ocorrência somente de "atos de cogitação e preparatórios". Neste sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Consumo - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767 - grifei

"TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739 - grifei

Inafastável, assim, a condenação dos réus nos termos da denúncia, mas entendo não ser, no caso, aplicável a agravante genérica, pois não demonstrado que a calamidade pública da pandemia do COVID 19 influiu na prática do delito, ainda mais considerando a data dos fatos, em que a pandemia sabidamente já havia arrefecido. Finalmente, não há meios para a pretensa desclassificação para o art. 35 da Lei de Drogas, até porque não se verifica o vínculo associativo estável entre os réus. Decidida a tipificação, passo a aplicar aos réus a sanção merecida, nos termos do art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

ANDRÉ (fls. 102/103) e DANILO (fls. 99/101) são reincidentes (DANILO específico). DIOGO é reincidente e portador de maus antecedentes (fls. 95/98). SUELLY é tecnicamente primária, embora responda a outro processo idêntico (fls. 93/94). Assim, atenta às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerando os maus antecedentes de DIOGO, fixo sua pena base acima do mínimo legal em seis anos de reclusão e pagamento de 600 dias multa, utilizando o valor unitário mínimo e no mínimo legal, em cinco anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal, para ANDRÉ, DANILO e SUELLY.

Deixo de atenuar a pena em razão da menoridade relativa de SUELLY por ter fixado a pena-base no mínimo legal (Súmula nº 231 do C. STJ).

Deixo, outrossim, de aplicar a causa de redução de pena preceituada no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos a DIOGO, ANDRÉ E DANILO pela reincidência dos acusados. Pela reincidência de DIOGO, ANDRÉ E DANILO, de rigor a exasperação da pena em 1/6, totalizando sete anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa para DIOGO e em seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa para ANDRÉ e DANILO.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte dos acusados.

Por outro lado, quanto a SUELLY, que é primária, revendo posicionamento anterior desta magistrada, considerando o advento da Lei nº 13.964/19, que em tese alçou o tráfico de pessoa primária e com relativamente pequena quantidade de droga hábil à não persecução penal, com base no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, diminuo a pena em 1/3, considerando que os acusados estavam na posse de grande quantidade de entorpecentes diversos, totalizando três anos e quatro meses de reclusão e pagamento 333 dias-multa.

Não existem outras causas de oscilação a serem consideradas, pelo que torno definitiva a pena imposta, mantendo a unidade do dia-multa no mínimo legal ante a falta de comprovação de boa situação financeira por parte da acusada.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para:

- 1) CONDENAR o réu DIOGO FELIPE GABRIEL LIMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de sete anos de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 700 dias-multa, com unidade no mínimo legal;
 - 2) CONDENAR os réus ANDRÉ LUIS SANTOS DA SILVA e DANILO GOMES DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 583 dias-multa, com unidade no mínimo legal;
 - 3) CONDENAR a ré SUELLY APARECIDA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena total de três anos e quatro meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 333 dias-multa, com unidade no mínimo legal.
- Os réus não fazem jus a qualquer benefício, dada a reincidência de ANDRÉ, DIOGO E DANILO, bem como a pena aplicada e a hediondez do delito pelo qual foram condenados, não reputando presentes os requisitos do art. 44, III, ou 77, II, ambos do CP. Neste sentido: "(...)A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra adequada, quando não atendidos os requisitos subjetivos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 5. Precedentes do STJ. 6. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial" (STJ, HC 91.822/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, grifei).

Com base no art. 33, §3º, do Código Penal, determino que os réus ANDRÉ, DIOGO e DANILO deverão iniciar o cumprimento de suas penas de reclusão em regime fechado, tendo em vista a pena aplicada, reincidência, a hediondez do delito pelo qual são condenados e a necessidade da prevenção do tráfico de drogas, que se expande cada dia mais com a benevolência dos aplicadores da Lei. Neste sentido:

"Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem, com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir

aqueles que transgridem em plena confiança de impunidade a ordem jurídica em que a legislação se sustenta. Ora. O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um fenômeno social, dê-se que a própria Justiça é um ideal humano. Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores básicos através dos Poderes do Estado. Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação do Judiciário não pode perder este Norte. O julgador, portanto, que é agente político, de evidente função social, aplicador da Lei, deve guiar a este sentido, 'data venia'. Daí que aquele que infringe as normas penais, dá um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em que convive, momento em que sujeita-se, de forma consciente, à atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva. Com isso, não se pode jamais perder de vista que o tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo o mundo da criminalidade. Daí que aquele que se dispõe a disseminar entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da própria sociedade. Merece, por isso, fixação de regime inicial compatível com as circunstâncias e consequências do delito por ele praticado. Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal), o que não se pode permitir." (TJSP, 4ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0005862-19.2013.8.26.0091, Relator Desembargador Luis Soares de Mello, Mogi das Cruzes, negaram provimento, v.u., j. 25/08/2015).

E ainda:

O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos. O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais. Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas. Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave. Mas há os considerados hediondos. Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável. Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado? O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o "crack", por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo. A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social. O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados. Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destruir outras sociedades, outras inúmeras famílias. Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa. O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal como procedeu o Legislativo. Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é absolutamente inadmissível. Como aplicar

ao traficante, por exemplo, a prestação de serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive! O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de que se trata de crime gravíssimo. Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado. Em liberdade, ou mesmo em regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação nº 0084044-40.2016.8.26.0050, Relator Desembargador Poças Leitão, São Paulo, negaram provimento, v.u., j. 30/11/2017 - grifei).

E mais, as reincidências dos acusados e esta nova condenação indicam nenhum regime menos gravoso é capaz de coibir sua conduta delinquente. Nesse sentido:

"tratando-se de condenado reincidente, qualquer que seja a pena de reclusão aplicada, ele deve inicia-la em regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, alínea 'c', do Código Penal" (TJSP, AC nº 0000466-79.2011.8.26.0625, Relator Desembargador Penteado Navarro)

E ainda:

"Não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição do meio inicialmente fechado para o desconto da reprimenda, pois, nada obstante ser a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a reincidência do réu justifica o estabelecimento do meio prisional mais severo, conforme a dicção do art. 33, §§2º e 3º, do Estatuto Repressor. Precedentes" (STJ, 361766/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado 20-10-2016, grifei).

"Permanecendo inalterado o quantum de reprimenda, deve ser igualmente mantido o regime prisional fechado, pois, conquanto seja a pena inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a sua reincidência justifica a imposição do meio mais gravoso para o início do desconto da sanção corporal a ele imposta" (STJ, HC 358421/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, j. 08/11/2016, grifei).

Consoante o art. 387, §2º, do CPP, mantenho o regime prisional acima fixado, pois inexistem informações sobre o comportamento carcerário dos acusados para a progressão de regime, consoante o art. 112 da LEP. Neste sentido: TJSP, 3ª Câmara Criminal, AC nº0045877-82.2014.8.26.0224, relator Desembargador Luiz Antonio Cardoso; TJSP, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, AC nº0004038-54.2014.8.26.0361, relator Desembargador Luiz Augusto de Sampaio Arruda.

Nos termos do §1º do art. 387 do Código de Processo Penal, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva, MANTENHO a custódia cautelar dos réus ANDRÉ, DANILO e DIOGO, ante a manifesta periculosidade que apresentam, suas reincidências e reiterações criminosas, inalterada a situação fática que determinou a decretação de suas prisões anteriormente, presentes, sem dúvida, os requisitos do art. 312 do CPP, não se justificando, agora que se acolheu a pretensão estatal para condenar os acusados, ordenar a libertação deles, sem prejuízo do conhecimento de eventual apelação a ser interposta.

Recomendem-se os réus no local em que se encontram presos.

Com relação à ré SUELLY, por outro lado, em atenção ao disposto no §3º ao art. 33 do Código Penal e, como exposto acima, revendo posicionamento anterior, determino que a ré deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com base no art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em favor da União Federal. Autorizo a destruição da droga apreendida, se ainda não foi feito. Providencie-se o necessário.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva; intime-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa imposta (se o caso); e oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD) e ao TRE/SP, tendo em vista o disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. R. I. C.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA